

1500944-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM DOS AGENTES PELA AUTORIDADE POLICIAL. FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. OFENSA À INTIMIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500944-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500944-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008552/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 22369285 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 110/22/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2008552 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE ROGERIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

JOSE ROGERIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 12h20min, na Rua Oito, altura do numeral 100, Jardim Paulistano, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 invólucros plásticos contendo 7,5 g de substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como maconha; 56 invólucros contendo 37,6 g de cocaína; e 53 invólucros contendo 12,9 g de cocaína do tipo "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, policiais militares realizavam

patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu em atitude suspeita, apoiado em um carro antigo e fazendo anotações em um papel, razão pela qual decidiram abordá-lo. Procedida a abordagem, localizaram com JOSE ROGERIO a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), bem como uma folha de papel com a contabilidade do tráfico e, em cima da roda do automóvel, uma bolsa contendo os entorpecentes acima descritos. Indagado pelos policiais, JOSE ROGERIO afirmou que encontrou as drogas abandonadas no local. Diante dos fatos, foi preso em flagrante.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Preliminar (fls. 106), sendo recebida a denúncia (fls. 106) e efetivada sua citação, designando-se audiência na qual ouvidas duas testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com a fixação da pena acima do mínimo legal, em razão dos seus antecedentes criminais e sem a aplicação do redutor, pelo mesmo motivo, fixando-se o regime inicial fechado; sem direito de apelar em liberdade e sem a substituição por pena alternativa.

A Defensoria Pública postulou em memoriais (fls. 148) a nulidade pela quebra da cadeia de custódia. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação de pena mínima, reconhecimento do redutor no tráfico em seu grau máximo, regime inicial aberto, substituição por pena restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

Impossível o reconhecimento da nulidade da prova colhida por quebra da cadeia de custódia. Ora, a defesa acaba por deturpar o conteúdo do artigo 158 do CPP ao interpretar que em qualquer apreensão de drogas deverá o policial isolar o local para que não se altere o estado das coisas, até que o perito realize a coleta. Nestes termos observo que o artigo 158-A do CPP define cadeia de custódia como "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

Nestes termos o legislador pátrio inovou ao prever as etapas da cadeia, indicando que "o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime OU com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

Logo, a leitura do artigo deve ser feita de acordo com as circunstâncias do delito que se pretenda investigar, sendo certo que determinados delitos demandam o isolamento e outros não, ficando a cargo da autoridade policial as determinações que entender pertinentes. No caso em tela, observa-se que as substâncias foram regularmente apreendidas (vide auto de exibição e apreensão de fls. 08), encaminhadas devidamente lacradas ao IC (Lacre 1464429), sendo constatadas por perito oficial (laudo de constatação de fls. 24) e posteriormente analisadas com toda a metodologia, comprovando-se sua materialidade através de Laudo químico-toxicológico (fls. 102), tudo como determina a Lei 11.343/06. Não há qualquer indício de que tenha havido quebra de idoneidade do caminho da prova.

De se destacar ainda que o artigo 158-C prevê que a "coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.". Em recentes casos de apreensões o STJ já se manifestou

sobre a cadeia de custódia:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM DOS AGENTES PELA AUTORIDADE POLICIAL. FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

AUSÊNCIA DE MÁCULA. OFENSA À INTIMIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INST NCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OBSERV NCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COLHEITA DE PROVAS E PERÍCIA PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS ANTES DA AUDIÊNCIA. NÃO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.

AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) VIII - A atuação policial na coleta das provas, a preservação do cenário delitivo e a apuração pericial não estão inquinados de mácula configuradora de nulidade processual. Ao contrário do verbo defensivo, as normas referentes à colheita da prova (a exemplo do auto de exibição e apreensão) e da sua perícia probatória (como a feitura do laudo definitivo) foram observadas, revelando a concretização do princípio do devido processo legal no caso em exame, assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(AgRg no RHC 141.113/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

No mérito, a materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo Laudo de constatação de fls. 25 e químico-toxicológico de fls. 102. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 17), o réu informou que foi ao ponto de vendas para comprar crack. Lá chegando, viu as drogas e anotações e deu uma olhada, momento em que abordado. Judicialmente, disse ser usuário de crack, acordou e foi comprar duas porções de dez reais de crack. Sabia que a droga ficava escondida e encontrou o papel com números e quantias. Parou para ler e cumprimentou os policiais. Na entrada da avenida, 100 metros à frente, foi abordado e pegaram o cachimbo, o dinheiro e o cigarro. Não viu a droga escondida. Não havia mais ninguém. Terminou de cumprir as penas em 2015. Não conhecia os policiais anteriormente. Tem um casal de filhos de 20 anos e 18 anos. Estava fazendo bico de pedreiro antes de ser preso. A anotação estava perto do carro, no chão, perto da porta de uma casa. Já foi processado por tráfico e absolvido. Tem muitos traficantes ali, homens e mulheres.

A testemunha Roger, policial militar, reconheceu o réu em audiência. O local tem tráfico e viram o réu com papel e caneta fazendo anotações, escorado em um carro. Ao ver a equipe, ele saiu andando, mas, foi abordado. O papel que dispensou tinha anotações e embaixo do veículo em que ele estava escorado, estavam as drogas, perto da roda, na parte da frente do veículo. O acusado estava sozinho. Havia porções de maconha, cocaína e crack. O réu disse que foi comprar entorpecentes, mas não havia ninguém lá e ele encontrou o papel e começou a ler. Não havia denuncia no dia, houve em outros dias. Não conhecia o réu anteriormente. Havia 20 reais no bolso do shorts dele.

A testemunha Kaique, policial militar, reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento de rotina e o local tem tráfico. Viram o réu fazendo anotações escorado em um carro. Ao ver a equipe, ele saiu andando, mas, deixou o papel. Embaixo do carro, havia a bolsa com as drogas. Ele tinha 20 reais no bolso. Havia porções de maconha, cocaína e crack embaladas para venda. O acusado estava sozinho. Neste dia, usavam câmera no local. O réu ficou em silêncio.

Desta forma, a prova acusatória é segura e autoriza a condenação do réu pelo delito narrado na exordial. Ora, os policiais foram seguros em imputar ao réu a posse de anotações, indicando que os entorpecentes foram encontrados no veículo onde estava ele escorado. Tais relatos, em nada desbordam das filmagens do link de fls. 139, eis que os PMS relatam que o réu deixou o local e saiu andando, pelo que ficou um pouco distante das drogas. Sobre o valor de tais relatos já se decidiu:

"O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que a contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor são justificáveis. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nestes autos." (TJSP – AC 205162-3/4 – Rel. Jarbas Mazzoni – RT 733/566).

Interrogado, o réu negou a traficância, indicando que apenas mexia no local onde estavam escondidas as drogas, pegando o papel das anotações para ler, versão que não se mostra crível.

A quantidade das drogas e o contexto do flagrante evidenciam que estas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros e não para consumo próprio, impedindo a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, aumento a pena em um sexto.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, em vista do não cumprimento dos requisitos exigidos, diante de seus maus antecedentes (certidão de fls. 56/58). Neste sentido é a decisão abaixo:

RE no AgRg no AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1713569 - SP (2020/0141624-4) DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por GUSTAVO HENRIQUE BADOÇO BALDOINO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 658-659): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado possui maus antecedentes, tanto é que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 4. Não há que se falar em bis in idem pela exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, bem como pelo afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) Prosseguindo, busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Assim, a configuração da reincidência e dos maus

antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes: AgRg no HC n. 425.954/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018; AgRg no AREsp n. 1.124.693/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018; AgRg no HC n. 421.000/RS, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 30/4/2018; HC n. 404.229/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018; HC n. 397.129/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado possui maus antecedentes, tanto é que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. Ademais, não há que se falar em bis in idem pela exasperação da pena-base, em razão dos maus antecedentes, bem como pelo afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes: AgRg no HC 593.509/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020; AgRg no RESp 1845195/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; AgInt no AREsp 1350765/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018. (...)
Brasília, 16 de dezembro de 2020. JORGE MUSSI Vice-Presidente RE no AgRg no AgRg no AREsp 1713569 SP 2020/0141624-4 Publicação DJ 17/12/2020 Relator Ministro JORGE MUSSI

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, diante do montante e da primariedade. Ademais, o réu cumpriu a pena em regime fechado por quase oito meses, até ser beneficiado com a liberdade provisória, sendo por demais rigoroso o regime inicial fechado.

Pelo mesmo motivo, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou aplicar o sursis, os quais seriam inviabilizados pelo montante da pena.

Faculto o apelo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar neste momento.

4- Em face ao exposto julgo procedente a ação penal para condenar JOSE ROGERIO DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

PRIC

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA